

1505279-95.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... é elemento valioso na análise da adequação típica do tráfico de drogas. Sobre o assunto:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO RECURSAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO DE DROGAS. AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INFORMANDO A PRÁTICA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505279-95.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505279-95.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302770/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 21248171 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

2225/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2302770 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS,

2225/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO FERNANDO ALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

KAIO FERNANDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Consta da denúncia que no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 20h15min, na Rua Olímpio Coelho Tupinã, nº. 499, Vila Christoni, nesta cidade e Comarca de Ourinhos/SP, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 5 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida de 18,3 (dezoito gramas e três centigramas) e 06 pedras de "crack", com massa líquida de 2,1 (duas gramas e uma centigrama), drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de constatação provisória de fls. 13/15. O réu foi notificado (fl. 105) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fls. 110/112).

A decisão de fl. 115 recebeu a denúncia no dia 02 de fevereiro de 2022.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 156).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foi ouvida uma testemunha comum.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, requereu a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com a consideração da atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade do acusado KAIO FERNANDO ALVES DA SILVA, pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada.

Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/10, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, fotografias de fls. 14/15, laudo de constatação provisória de fls. 18/19, conjugado com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 128/131, relatório de investigação de fls. 132/134, sem deixar de mencionar a prova oral colhida, cristalina quanto a prática do delito de tráfico de drogas.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas inquiridas e das circunstâncias do caso concreto.

Na fase extrajudicial, a testemunha Marcos Paulo Leite declarou que teve uma discussão com sua esposa e saiu de sua residência, quando encontrou o réu na esquina e lhe perguntou se possuía maconha para vender, quando foram abordados pelos policiais militares. Não chegou a adquirir a droga, bem como não soube informar o valor da droga cobrada pelo réu, pois foram interceptados pela polícia. Nunca adquiriu drogas com o réu anteriormente, mas costuma adquirir drogas na Vila Marcante com outros indivíduos. Já foi preso anteriormente por furto, porque era usuário de "crack". (fl. 05 - mídia audiovisual).

Na fase extrajudicial, o policial militar Marcelo da Silva Zanirato declarou que estava em patrulhamento pela Rua Olímpio Coelho Tupinã quando avistou dois

indivíduos fazendo uma transação de drogas. O local já é conhecido pela prática de compra e venda de drogas. O indivíduo que estava segurando umas embalagens, ora réu, o qual também já é conhecido nos meios policiais, ao ver os policiais militares dispensou a referida embalagem no chão e ao ser abordado o réu tentou correr, porém foi detido. Visualizou as embalagens, e em uma embalagem de cor branca havia uma porção de maconha e na outra embalagem de cor verde com três pedras de crack. Foi indagado o réu e o usuário de nome Marcos, separadamente, sendo que Marcos respondeu que estava naquele local para comprar maconha com o réu Kaio e estava com a quantia de R\$ 50,00 em notas diversas. Mas, compraria uma quantia de R\$ 5,00 de maconha com o réu. Por sua vez, ao realizarem a busca pessoal no réu foi encontrado consigo, no bolso de sua bermuda, mais quatro porções de maconha e em uma embalagem transparente mais uma porção de crack bruta e mais uma porção pequena de crack, além do valor de R\$ 192,00 em notas diversas, bem como um aparelho celular. O réu confessou que estava vendendo drogas e que vende a porção maior de maconha a R\$ 10,00 e a porção menor a R\$ 5,00, já a pedra de crack a R\$ 10,00. O réu é conhecido nos meios policiais e já foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas. (fl. 03 - mídia audiovisual).

Na fase extrajudicial, a testemunha Diego Ferreira declarou que estava em patrulhamento com o seu colega de farda, quando acessaram a Rua Olímpio Coelho Tupiná e avistaram Kaio, ora réu, e Marcos, fazendo gestos que pareciam uma negociação, diante da suspeita e do fato do réu já ser conhecido nos meios policiais foram até eles para realizarem a abordagem. Quando o réu dispensou no chão duas embalagens plásticas. Constatou que na embalagem plástica transparente havia uma porção de maconha, já na embalagem verde havia três porções de crack. Em busca pessoal, com o réu foi localizado uma pedra bruta de crack e mais algumas porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 192,00, em notas diversas. Indagado Marcos, este informou que estava naquele local para adquirir drogas com o réu. O réu confessou a traficância, informou que estava desde o período da manhã vendendo drogas e que o dinheiro encontrado era fruto destas vendas. O réu é conhecido nos meios policiais pelo mesmo crime, e que naquela data seria o terceiro dia, consecutivo, que estava sendo apresentado na delegacia de polícia. No primeiro dia que o réu foi conduzido a delegacia, foi porque este tentou se evadir da abordagem policial com sua motocicleta, porém foi interceptado pela polícia militar e no segundo dia, este estava em posse de um aparelho celular que teria sido adquirido por dez pedras de crack, com um usuário de drogas. A terceira vez foi na data de hoje, quando foi flagrado vendendo drogas. Todas as abordagens ocorreram no mesmo local (fl. 04 - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Diego declarou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento e acessaram a rua Rua Olímpio Coelho Tupiná e avistaram dois indivíduos fazendo transação. Ao visualizar a equipe policial, um dos indivíduos tentou dispersar algo ao chão e tentou se evadir. Foi realizada a abordagem, o indivíduo que tentou se evadir foi reconhecido como Caio e o outro indivíduo como Marcos, o que disse que estaria naquele local para adquirir drogas com o Caio. Com Caio, arrecadaram o objeto que ele tinha dispensado e se tratava de de uma porção de maconha embalada em papel plástico de cor branca e outra embalagem verde contendo três pedras de "crack". Em busca pessoal, foi localizada com Caio foi localizada R\$ 192,00 em dinheiro, em notas diversas, bem como 4 porções de "maconha" semelhantes a que ele havia dispensado e mais uma quantidade de "crack". Ao ser indagado, Caio disse que vendia a maconha por R\$ 5,00 a porção pequena e R\$ 10,00, a porção grande e R\$ 10,00 a porção de "crack". Caio ainda disse que o dinheiro que ele estava seria oriundo da venda das drogas. Caio já é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, inclusive essa abordagem era o terceiro dia consecutivo em que Caio tinha sido conduzido para a Delegacia. Na abordagem do primeiro dia, foi dado voz de parada e Caio se evadiu com uma motocicleta, porém depois foi abordado. No dia seguinte, ele foi pego com um aparelho celular produto de furto e no terceiro dia ele foi abordado com droga. Interrogado em seu auto de prisão em flagrante, o réu declarou que a droga encontrada era sua e que iria vendê-la porque está desempregado e está passando por dificuldade. Disse que estava vendendo drogas na data de hoje, sendo que a porção

de maconha e crack custam cerca de R\$ 10,00 cada. Já tinha vendido R\$ 180,00 de drogas na data de hoje, confirmou que o dinheiro encontrado com ele é fruto da traficância. Também é usuário de drogas, como cocaína, crack e maconha. Não faz muito tempo que está na traficância, "não faz um mês" e, ainda, informou vender as drogas no bairro Vila Christoni e nos seus arredores. Já teve passagem pela polícia pelo crime de tráfico. Possui lesões no corpo, mas não são referentes à data de hoje e sim a outros fatos (fl. 07 – mídia audiovisual).

Interrogado em Juízo, o réu declarou que a droga era dele, mas era para seu consumo. Nega o tráfico. Indagado sobre o relato prestado perante a autoridade policial quando de sua prisão em flagrante, em que assumiu o tráfico de drogas, o réu disse que não se recordava porque estava sob efeito de drogas. Confirmou que estava com celular no momento da sua prisão, e que foi apreendido. Disse que não se recorda sobre as conversas de tráfico de drogas encontradas em seu celular. Não tem nada contra o policial que depôs nos autos. Disse que o "rapaz" o parou na rua e perguntou se alguém por perto tinha "maconha" para vender. Foi quando os policiais passaram e o avistaram em atitude suspeita e o abordaram e acharam a droga. Tinha 18 gramas de "maconha" e 06 pedras de "crack", além de R\$ 192,00, que era de seu trabalho de ajudante de pedreiro. Já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Ourinhos. Quando adolescente respondeu a 5 ou 6 atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e cumpriu liberdade assistida e ficou internado na Fundação Casa por 1 ano e 1 mês, saindo com 18 anos.

Encerrada a instrução processual, a autoria é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre o réu Caio.

O réu, embora tenha assumido a propriedade da droga apreendida, negou que se destinasse ao tráfico e sua negativa está isolada no acervo probatório.

A traficância está bem evidenciada, cristalina.

Os policiais militares narraram que visualizaram o réu fazendo com outro indivíduo contato típico do tráfico de drogas e que ao se aproximar o réu dispensou duas sacolas plásticas, uma contendo porção de "maconha" e a outra com pedras de "crack". Em busca pessoal, os policiais encontraram com o réu mais uma pedra bruta de "crack" e mais algumas porções de "maconha", bem como a quantia de R\$ 192,00, em notas diversas. Indagado, o outro indivíduo visualizado fazendo contato com o réu, informou que estava naquele local para adquirir drogas com o réu. Os policiais disseram que na ocasião o réu admitiu o tráfico, disse que estava desde o período da manhã vendendo drogas e que o dinheiro encontrado era fruto dessas vendas. Os policiais ainda narraram que havia informações do tráfico de drogas praticado pelo réu.

Assim, as drogas apreendidas, que o réu trazia consigo, sem dúvidas, destinavam-se à venda, o que se extrai das circunstâncias do caso concreto, vale dizer, pela quantidade, variedade, natureza e modo como acondicionadas (5 porções de "maconha", com massa líquida de 18,3 g e 06 pedras de "crack", com massa líquida de 2,1 gramas); pelo conteúdo encontrado no celular do réu, com diálogos de venda de drogas pelo réu, consoante se observa do relatório de investigação de fls. 171/172; aliado ao relato das testemunhas, policiais militares, que visualizaram o réu em contato com outro indivíduo, e, ao ver os policiais, correr e dispensar invólucros contendo "maconha" e "crack".

Vale recordar, que, ao contrário do que pretende a combativa Defesa, a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, terem depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de

drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos." (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01.07.2016) "TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido Recurso improvido." (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01.04.2015).

Por outro lado, os depoimentos prestados pelos policiais foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo qualquer elemento que permitisse a ilação de que os policiais envolvidos estariam animados do propósito de incriminar indevidamente os acusados.

"PROVA - DEPOIMENTO POLICIAL - Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim" (TJSP - Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 - Origem: São Vicente - Relator: Des. Marcos Zanuzzi - J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições. A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente os réus, seus depoimentos merecem crédito assim como os de qualquer outra testemunha. Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

Quanto as denúncias que recaiam sobre o réu, no sentido de que estaria praticando o tráfico de entorpecentes, é certo que isoladamente denúncias anônimas não possuem o condão de condenar alguém, mas aliadas a outros elementos probatórios constituem indícios concretos da prática delitativa, como é o caso dos autos, em que houve campanhas que precederam ao cumprimento do mandado de busca domiciliar, na qual efetivamente ocorreu a apreensão de entorpecentes, além de objetos relacionados à atividade torpe.

Como se observa, ainda que as denúncias anônimas sejam provas indiciárias, quando corroboradas por outras provas dos autos é elemento valioso na análise da adequação típica do tráfico de drogas. Sobre o assunto:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO RECURSAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO

COESO E APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO DE DROGAS. AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INFORMANDO A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA PELO APELANTE, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E A POSSE DO RÉU DE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEMONSTRAM SUA RESPONSABILIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DO CP. QUANTIDADE DOS TÓXICOS APREENDIDOS E PROVA NA HABITUALIDADE NA VENDA E PLANTIO, NÃO AUTORIZAM SUA APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO" (TJPR - 4ª C.Criminal - AC 0662493-3 - Siqueira Campos - Rel.: Des. Miguel Pessoa - Unânime - J. 01.07.2010) - destaquei.

Assim, as denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia e, quando são confirmadas com elementos concretos nos autos, merecem guarida para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assuma sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam. Pontuo que a alegação do réu de que a droga apreendida se destinava ao seu consumo é mendaz e contraditório, e isolada no acervo probatório, não merecendo a menor credibilidade.

Com efeito, tanto aos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, quanto perante a autoridade policial, em depoimento gravado em formato audiovisual (fl.07), o réu admitiu o tráfico de drogas na ocasião e que o dinheiro com ele apreendido era fruto da venda de drogas. Em Juízo o réu alterou a versão dos fatos, certamente na tentativa de atenuar sua responsabilidade, mas sem infirmar o robusto acervo probatório que demonstra o tráfico por ele praticado.

Vale ressaltar que por ocasião de sua prisão o réu trazia consigo um aparelho celular, o qual foi apreendido e, após autorização judicial, foi objeto de extração de dados, que revelou conversas pelo aplicativo messenger do facebook em que o réu realiza a venda de droga para outros indivíduos, conforme pode ser observado as fls. 171/173.

Saliento, ainda, que a simples declaração de ser usuário de droga não descaracteriza a traficância. Ainda que o acusado seja realmente usuário de droga (o que sequer restou demonstrado nos autos), tal circunstância não exclui sua condição de traficante. Ao contrário, reforça-a, pois é comum que o usuário venda droga para manter seu vício.

Assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS Tráfico Alegação de ser o acusado usuário de entorpecentes. Irrelevância. Hipótese em que uma conduta não exclui a outra, sendo comum o tráfico entre dependentes ou usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo Recurso improvido." (TJSP. Apelação Criminal n. 1.167.864.3/4 Ibitinga 5ª Câmara Criminal, Relator: Juvenal Duarte 15.05.08 M.V. Voto n. 2.478)

No caso dos autos, a prova demonstra seguramente que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao comércio, circunstância que impede a desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 para a do artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Assim sendo, os argumentos defensivos ficam sem guarida nenhuma nos autos, de modo que acolho a imputação de tráfico de drogas.

Quanto ao valor em dinheiro, é de rigor a conclusão de que era proveniente do tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Assim, pelas condições reveladas acima, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, é imperioso o reconhecimento da prática pelo réu KAIIO FERNANDO ALVES DA SILVA do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à aplicação de suas penas.

Na primeira fase de dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, já que traficava "maconha" e "crack", conhecida por sua natureza altamente viciante, destrutiva e nociva à saúde humana.

Assim, "Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e

tráfico de tais entorpecentes" (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP, julgamento em 03.05.2011).

Sobre a nocividade da cocaína na forma de "crack", transcrevo trecho de julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Oportuno destacar que, em matéria jornalística veiculada na Folha de S. Paulo do dia 31.5.2015, noticiou-se estudo indicativo de que ao menos 1.685 pessoas morreram no Est. de S. Paulo em 2013 após terem consumido cocaína, uma média de cinco óbitos diários. E, "Segundo especialistas, o crack é 'cinco vezes mais potente que a própria cocaína e produz dependência com muita facilidade e quase imediatamente após seu primeiro ou segundo uso (...) Os efeitos produzidos ao usuário são basicamente iguais ao da cocaína, porém muito mais intensos (...)'" (João Gaspar Rodrigues, Tóxicos, Bookseller, 2001, p. 63)" (RT, 838/571). Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade ao organismo humano, tornando o usuário, em curto - período de tempo, "escravo do desejo de consumir o entorpecente". Note-se, por oportuno, que "A cocaína fumada na forma de crack (...) possui ação farmacológica comparável à cocaína" (v. Toxicologia Forense cit., cap. V, nº 1.3.1, pág. 136)" (TJSP. Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade.

Portanto, essa circunstância (natureza) autoriza a exasperação da pena em face da maior reprovabilidade da conduta, na esteira do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a quantidade e natureza da droga como circunstância preponderante na fixação da pena base.

Nesse sentido:

1. A natureza da droga apreendida - cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, HC 338379/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 06.12.2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Ag regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 476995 / SC, 5ª Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgamento em 03.05.2019.)

"O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12).

"No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base, amparada no art. 59 do Código penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Precedentes" (STJ, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). No mesmo sentido: STJ, HC 84.269-MS, 5ª Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u.)

Assim, em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas (natureza e variedade das drogas), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, considero a atenuante da menoridade relativa.

Assim, reduzo a pena para o mínimo de 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal. Pontuo que em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ, a incidência de atenuante não pode conduzir a pena mínima abaixo do mínimo legal.

Torno a pena definitiva, à mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena. Saliento que o caso concreto não se ajusta à figura do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois restou demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa. Com efeito, o réu, que por ocasião de sua prisão contava com 20 anos, narrou que quando adolescente respondeu a 5 ou 6 atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e que cumpriu liberdade assistida e ficou internado na Fundação Casa por um ano e um mês, de lá saindo com 18 anos, além de narrar que possui condenação pela prática do tráfico de drogas nesta Comarca, o que é corroborado pelas certidões de fls. 38/39 e 40/41, que confirma a condenação do réu por tráfico de drogas. Referida dedicação do réu ao crime também é corroborada pela narrativa dos policiais de que o réu era conhecido pela prática do tráfico de drogas e também porque por ocasião de sua prisão o réu trazia consigo um aparelho celular, o qual foi apreendido e, após autorização judicial, a extração dos dados revelou conversas pelo aplicativo messenger do facebook, ocorridas em 27.10.2021, em que o réu realiza a venda de drogas para outros indivíduos, conforme pode ser observado às fls. 171/173, evidenciando o tráfico reiterado de entorpecentes, seu profundo envolvimento com a criminalidade e que não se trata de uma traficante de primeira viagem (o que ensejaria a aplicação do redutor), e permite concluir que fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, estando inserida no espúrio comércio há algum tempo.

Vale rememorar o texto legal:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput em o §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (destaquei).

Nesse sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA E PETRECHOS) – O RECURSO MINISTERIAL OBJETIVA APENAS QUE SEJA FIXADO O REGIME FECHADO – COM RAZÃO – SEQUER ERA CASO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE, POIS DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO RÉU AO TRÁFICO, POIS JÁ TEVE PASSAGEM PELO JUÍZO DA INFÂNCIA POR CONDUTA ANÁLOGA – TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM – TAMBÉM HOUVE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO, MAS QUEDOU-SE INERTE O MINISTÉRIO PÚBLICO – A PENA FOI FIXADA COM BRANDURA – DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS, DE RIGOR O REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA FIXAR REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUANDO ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA." (Apelação Criminal nº 0000013-19.2018.8.26.0438, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, julgamento em 27.08.2019) (destaquei)

Dada a natureza do crime, equiparado constitucionalmente aos hediondos; a quantidade de pena aplicada; a natureza e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e "crack"), sendo necessário o efetivo combate a tão grave conduta, concretamente considerada, entendo que o único regime adequado e suficiente para início de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal, é o fechado.

E, pelos mesmos fundamentos, entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por meras restritivas de direitos, incompatíveis com crime dessa natureza, ante sua equiparada hediondez, bem como insuficientes para o necessário combate ao comércio ilícito de drogas, que mais e mais assola a sociedade disseminando o vício. Inviável, igualmente, a aplicação do sursis.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considerando que o réu permaneceu preso processualmente durante toda a instrução do processo; o regime inicial fechado ora fixado, para assegurar a futura aplicação da Lei Penal e especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, já que o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa, evitando-se a



reiteração de condutas tais como a imputada, não lhe faculta a oportunidade de recorrer em liberdade, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra e expedindo-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu KAIÓ FERNANDO ALVES DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime. O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, expedindo-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso. Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais. Com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD. Quanto aos demais objetos apreendidos, tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, e por considerá-los imprestáveis, determino o seu encaminhamento para imediata destruição após o trânsito em julgado. Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se as respectivas certidões. Sendo o réu assistido por defensor dativo, deixo de condená-lo às custas processuais. P.I.C.

Ourinhos, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA